

Dr Sameh Gharsallah**Docteur en droit public - Contractuel a l'institut supérieur
de gestion de l'Université de Gabes****La protection de la maternité en droit du travail : entre justice
sociale et discrimination positive****Introduction générale:**

La maternité, au croisement du biologique, du social et du juridique, représente un enjeu fondamental dans la construction des politiques publiques relatives à l'égalité entre les sexes. Longtemps marginalisée dans les systèmes juridiques fondés sur une égalité strictement formelle, la reconnaissance de la spécificité des besoins liés à la maternité a progressivement conduit les législations contemporaines à adopter des mesures correctives et protectrices, souvent qualifiées de discrimination positive. Ces mesures, loin de contrevenir au principe d'égalité, cherchent à instaurer une équité réelle, fondée sur la prise en compte des inégalités structurelles et de la vulnérabilité professionnelle des femmes enceintes ou mères.

En Tunisie, le droit du travail a connu, depuis l'indépendance, une évolution significative dans la manière dont il conçoit la maternité. Les premières dispositions, bien que pionnières à l'échelle régionale, restaient limitées tant dans leur portée que dans leur applicabilité. La loi n°66-27 du 30 avril 1966, premier texte de référence en matière de congé de maternité, prévoyait un congé de 30 jours, souvent jugé insuffisant pour assurer la protection de la mère et de l'enfant (JORT, 1966, p. 287). Par la suite, plusieurs ajustements ont été apportés, mais c'est avec la loi n°2024-44 du 12 août 2024 que la Tunisie opère une véritable refondation de son approche juridique.

Cette réforme ambitieuse, applicable à la fois dans la fonction publique et le secteur privé, élève le congé de maternité à 16 semaines intégralement rémunérées, renforce la protection contre le licenciement, introduit des droits spécifiques liés à l'allaitement et à l'aménagement du temps de travail, et instaure pour la première fois un congé de paternité légalement encadré. Elle s'inscrit ainsi dans une dynamique de convergence avec les standards internationaux, notamment les conventions de l'OIT (n°183, 2000) et les directives européennes, tout en répondant aux revendications des acteurs de la société civile tunisienne en matière d'égalité professionnelle et de justice sociale.

Problématique :

Dans quelle mesure la protection juridique accordée à la maternité dans le droit du travail constitue-t-elle une forme de discrimination positive, et comment cette protection peut-elle concilier équité professionnelle, justice sociale et performance économique ?

Cette problématique interroge à la fois :

- La légitimité de mesures spécifiques en faveur des femmes enceintes ou mères (ex. : congé maternité, interdiction de licenciement, aménagement du poste de travail),
- Et les enjeux liés à l'égalité réelle dans l'accès et le maintien à l'emploi, sans basculer dans un traitement inégalitaire ou stigmatisant.

Pour répondre à cette problématique, nous analyserons dans un premier temps le cadre juridique et les fondements de la protection de la maternité, avant d'envisager son rôle en tant que discrimination positive, puis d'ouvrir la réflexion sur ses limites, ses paradoxes et les perspectives d'évolution vers une égalité véritablement inclusive.

Axe 1 : Le cadre juridique de la protection de la maternité : entre droits fondamentaux et perspectives critiques dans le contexte tunisien

1.1. Normes internationales : fondement universel de la protection de la maternité

La maternité est reconnue comme une réalité universelle nécessitant un traitement juridique différencié afin de compenser les désavantages structurels subis par les femmes. Ce principe repose sur une série de conventions internationales que la Tunisie a ratifiées, engageant ainsi son droit interne à en refléter les standards.

L'OIT (Organisation Internationale du Travail)

La Convention n°183 (2000) pose les bases d'un droit international de la maternité:

- Minimum 14 semaines de congé maternité (art. 4) ;
- Interdiction de licenciement pendant la période de grossesse et de congé (art. 8) ;
- Droit au retour à un emploi équivalent (art. 8) ;
- Mesures de protection sanitaire pour les travailleuses enceintes (art. 3).

 OIT, *Convention 183, 2000, Genève, pp. 3-7.*

La CEDAW (1979)

Cette convention onusienne introduit l'idée d'élimination structurelle des discriminations, par la mise en place de mesures temporaires spéciales :

« [...] la maternité est une fonction sociale qui ne doit pas faire obstacle à l'égalité d'accès à l'emploi. » *CEDAW, art. 11.2, 1979.*

Le droit européen

La directive 92/85/CEE (UE) impose une protection de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, avec un congé minimal, un droit à l'aménagement du poste et une protection contre le licenciement. *JOUE, 1992, art. 8 à 10.*

1.2. Le droit tunisien : du Code du travail à la réforme de 2024

Avant 2024, la protection de la maternité en Tunisie était dispersée et inégalitaire, avec des écarts entre le secteur public et privé, et une prise en charge partielle des besoins réels. C'est dans ce contexte que la loi n°2024-44 du 12 août 2024 intervient comme une

réforme structurante, cherchant à unifier, prolonger et renforcer les droits maternels et parentaux.

3. Nouveautés majeures de la loi 2024-44

1. Unification des régimes public et privé : Tous les travailleurs et travailleuses bénéficient désormais des mêmes droits, ce qui corrige une discrimination institutionnelle entre fonctionnaires et salariés du privé. *Loi 2024-44, art. 1, JORT, août 2024, p. 12.*
2. Prolongation du congé maternité : Le congé passe à 16 semaines rémunérées à 100%, dont 6 semaines obligatoires après l'accouchement. La durée est conforme à la norme OIT, avec une prise en charge totale par la CNSS (secteur privé) ou le budget de l'État (secteur public). *Art. 3, p. 13.*
3. Renforcement de la protection contre le licenciement : Toute rupture du contrat pendant la grossesse ou dans les 12 semaines suivant le retour est interdite, sauf pour faute grave et après autorisation de l'inspection du travail. *Art. 6, p. 14.*
4. Nouveaux droits reconnus à la femme salariée :
 - Aménagement d'horaire à partir du 6e mois de grossesse, sans perte de salaire.
 - Temps d'allaitement : 2 pauses quotidiennes d'une heure, durant les 6 mois post-partum.
 - Congé spécial en cas de fausse couche, de naissance prématurée ou d'hospitalisation du nourrisson, avec couverture médicale. *Art. 9 à 12, pp. 15-16.*
5. Droit à la non-discrimination professionnelle post-maternité : Le texte prévoit expressément que le retour au poste doit se faire sans déclassement ni perte d'avantages acquis. *Art. 7, p. 14.*

1.3. Objectifs éthiques et sociaux de la réforme

La loi 2024-44 vise à :

- Renforcer la dignité des travailleuses mères, en sécurisant la période de maternité;
- Assurer une continuité professionnelle et lutter contre la précarisation post-maternité ;
- Traduire l'égalité constitutionnelle (art. 46 de la Constitution de 2014) en mesures concrètes, en reconnaissant la maternité comme une valeur sociale partagée, non un obstacle à l'emploi.

Cette approche repose sur une logique de discrimination positive, justifiée par l'objectif de compenser une inégalité structurelle due à la fonction reproductive.

1.4. Limites et critiques de la loi n°2024-44

1. Limites d'application et d'effectivité

La loi souffre d'un manque de mécanismes solides de contrôle et de sanction des employeurs qui ne respectent pas les dispositions, notamment dans les petites et moyennes entreprises ainsi que dans le secteur informel, où la majorité des travailleuses restent vulnérables (INS, 2023, p. 45). Par ailleurs, la charge de la preuve pour démontrer une discrimination ou un licenciement lié à la maternité repose souvent sur la salariée elle-même, ce qui limite l'accès effectif à la justice (Loi n°2024-44, art. 15, JORT, 2024, p. 17).

2. Limites sociales et culturelles

Malgré les avancées législatives, les stéréotypes et la stigmatisation sociale autour de la maternité en milieu professionnel persistent (OCDE, 2022, p. 59). Ces perceptions négatives influent sur la volonté des employeurs d'embaucher ou de promouvoir des femmes en âge de procréer. Par ailleurs, le congé de paternité limité à 10 jours ne favorise pas une réelle redistribution des tâches familiales, ce qui perpétue la charge principale de la parentalité sur les femmes (Loi n°2024-44, art. 13, JORT, 2024, p. 16 ; INS, 2023, p. 47).

3. Limites structurelles liées à l'emploi précaire

La loi n'inclut pas explicitement les travailleuses du secteur informel ou en situation précaire, un phénomène important en Tunisie où près de 50 % des femmes actives sont concernées (INS, 2023, p. 50). Enfin, bien que le congé maternité ait été prolongé à 16 semaines, cette durée reste en deçà des recommandations de certains organismes internationaux qui préconisent un congé plus long (de 20 à 24 semaines) pour assurer un équilibre optimal entre santé maternelle et réinsertion professionnelle (OCDE, 2022, p. 56).

Axe 2 : La protection de la maternité comme mécanisme de discrimination positive

2.1. Discrimination positive : définition, fondements éthiques et juridiques

La discrimination positive désigne l'ensemble des dispositifs légaux, institutionnels ou sociaux qui visent à corriger des inégalités historiques ou structurelles en faveur de groupes socialement défavorisés (Sen, 2000, p. 43). Elle se distingue d'une discrimination au sens négatif : elle est temporaire, justifiée éthiquement par la nécessité de rétablir une égalité réelle plutôt que formelle, et légalement reconnue dans plusieurs textes internationaux.

Sur le plan éthique, cette approche s'appuie sur la théorie de la justice distributive (Rawls, 1971), qui promeut l'idée que les inégalités ne sont justifiables que si elles bénéficient aux plus défavorisés, et sur la reconnaissance de la spécificité biologique et sociale des femmes.

Juridiques, les principaux fondements se trouvent notamment dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW,

1979, art. 4.1) qui autorise les États à adopter des mesures spéciales pour accélérer la réalisation de l'égalité des sexes, ainsi que dans les conventions de l'OIT (notamment la convention n°183, 2000).

Dans ce cadre, la maternité est une cause légitime et justifiée de traitement différencié, car elle engendre des contraintes physiques et sociales que les femmes seules supportent, générant ainsi des risques accrus de discrimination indirecte dans l'emploi.

2.2. La maternité comme facteur de vulnérabilité structurelle en milieu professionnel

La maternité génère une vulnérabilité professionnelle qui s'exprime à plusieurs niveaux :

2.2.1. Interruption et discontinuité de la carrière

La grossesse et la période postnatale entraînent une interruption nécessaire du travail. Cette absence peut avoir un effet cumulatif sur la carrière, notamment en termes de perte de promotion, d'accumulation d'expérience et de revalorisation salariale (OCDE, 2022, p. 57). L'absence prolongée fragilise la position de la femme au sein de l'entreprise.

2.2.2. Risque de discrimination indirecte

Les employeurs, anticipant ces absences, peuvent pratiquer une sélection défavorable à l'embauche des femmes en âge de procréer ou leur refuser des postes à responsabilités (INS, 2023, p. 44). Cette discrimination « préventive » est difficile à prouver et s'inscrit dans des représentations sociales souvent inconscientes.

2.2.3. Pression sociale et double charge

La maternité impose une double charge aux femmes, entre responsabilités familiales et exigences professionnelles, dans un contexte où les politiques de conciliation travail-famille restent insuffisantes (OCDE, 2022, p. 60). Ce déséquilibre contribue à la précarisation professionnelle et à l'augmentation du taux de départ anticipé des femmes du marché du travail.

2.3. La loi n°2024-44 : un cadre tunisien ambitieux de discrimination positive

La loi tunisienne n°2024-44 du 12 août 2024 constitue une réponse normative importante, illustrant concrètement la mise en œuvre de la discrimination positive en faveur des femmes mères.

2.3.1. Allongement et harmonisation du congé maternité

Le congé maternité est prolongé à 16 semaines — aligné sur les standards internationaux — et rémunéré intégralement, avec une prise en charge par la CNSS (secteur privé) ou l'État (secteur public). Ce renforcement de la protection sociale vise à réduire les risques économiques liés à la maternité, facilitant ainsi une meilleure insertion professionnelle (Loi 2024-44, art. 3, p. 13).

Cette mesure traduit un principe de justice sociale : reconnaître que la maternité exige des aménagements particuliers pour éviter que la femme ne soit pénalisée économiquement.

2.3.2. Protection juridique accrue contre le licenciement et précarisation

La loi interdit strictement le licenciement depuis la grossesse jusqu'à 12 semaines après la reprise, sauf exceptions très limitées. Cette mesure garantit une sécurité d'emploi essentielle et limite la précarisation des mères salariées, qui est souvent un frein majeur à l'égalité professionnelle (Loi 2024-44, art. 6, p. 14).

2.3.3. Aménagements du temps de travail et droit à l'allaitement

La reconnaissance légale des pauses pour allaitement (deux pauses quotidiennes d'une heure) et de l'aménagement d'horaires dès le 6e mois de grossesse, sans perte de salaire, sont des avancées significatives. Elles permettent d'adapter l'environnement professionnel aux besoins spécifiques des femmes enceintes et allaitantes, réduisant ainsi les inégalités d'accès à la performance professionnelle (Loi 2024-44, art. 9-10, p. 15).

2.3.4. Droit au retour à un poste équivalent

Le droit garanti à la salariée de retrouver son poste ou un poste équivalent avec les mêmes avantages assure la continuité de carrière et prévient le déclassement professionnel, un phénomène courant à l'issue du congé maternité (Loi 2024-44, art. 7, p. 14).

2.4. Effets et portée sociale : vers une égalité réelle

Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale visant à faire de la maternité une cause légitime de discrimination positive, dans le sens d'un rattrapage équitable des inégalités structurelles entre hommes et femmes. Elles témoignent d'une volonté de dépasser la simple égalité formelle pour créer les conditions d'une égalité substantielle.

Ce cadre légal, en valorisant la maternité plutôt qu'en la pénalisant, contribue à :

- Diminuer les freins à l'embauche et à la promotion des femmes ;
- Reconnaître socialement la maternité comme un facteur d'enrichissement plutôt que de faiblesse professionnelle ;
- Favoriser une répartition plus équilibrée des responsabilités familiales par la valorisation des droits parentaux.

Axe 3 : Limites, controverses et perspectives dans la protection juridique de la maternité

3.1. Risques de stigmatisation et de désincitation à l'embauche des femmes

3.1.1. Stigmatisation professionnelle liée à la maternité

La maternité, bien qu'étant une fonction biologique et sociale fondamentale, est encore fréquemment perçue dans certains milieux professionnels comme une source d'instabilité et de coût. Cette perception engendre une stigmatisation qui se manifeste

souvent par des pratiques discriminatoires implicites telles que l'exclusion des femmes enceintes des postes à haute responsabilité, ou la mise à l'écart lors des promotions (INS, 2023, p. 52).

Par exemple, des enquêtes montrent que dans plusieurs entreprises, les responsables des ressources humaines hésitent à embaucher des femmes proches de la maternité ou anticipent leur départ, ce qui aboutit à une forme de discrimination « préventive » difficile à détecter et à sanctionner (OCDE, 2022, p. 63).

3.1.2. Désincitation à l'embauche et conséquences économiques

La loi tunisienne n°2024-44 renforce les droits liés à la maternité, mais paradoxalement, ces protections peuvent entraîner une désincitation chez certains employeurs, particulièrement dans les PME ou les secteurs très concurrentiels, où la gestion du personnel est moins formalisée (Loi 2024-44, art. 6, JORT, 2024, p. 14).

Cette dynamique peut se traduire par :

- Une préférence accordée à des candidats masculins ou à des femmes hors âge « fertile » ;
- Des contrats précaires proposés aux femmes ;
- Une tendance à externaliser les tâches pour éviter les contraintes liées aux absences.

Cette situation appelle à un équilibre délicat entre la protection des droits des travailleuses et les besoins opérationnels des entreprises.

3.2. Inégalités persistantes malgré les progrès législatifs

3.2.1. Le plafond de verre : un obstacle structurel

Le concept de plafond de verre désigne les barrières invisibles qui empêchent les femmes d'accéder aux postes de direction ou de responsabilités, malgré leurs qualifications. La maternité joue un rôle aggravant dans cette dynamique, car elle est souvent associée à un « risque » de perte de productivité ou d'absence prolongée.

En Tunisie, bien que les lois protègent la maternité, le plafond de verre reste particulièrement élevé dans certains secteurs comme la finance, la haute administration ou les grandes entreprises, où les représentations culturelles de la femme-mère peuvent limiter son évolution (INS, 2023, p. 55).

3.2.2. Persistances des inégalités salariales

Les inégalités salariales entre hommes et femmes demeurent marquées, en partie à cause des interruptions de carrière liées à la maternité et des emplois à temps partiel subis. En effet, la maternité peut entraîner une décote salariale indirecte, avec une progression moins rapide des salaires et une moindre accumulation d'avantages sociaux (OCDE, 2022, p. 61).

La loi 2024-44 n'aborde pas explicitement cette problématique, ce qui révèle une limite importante dans la lutte contre les inégalités économiques liées au genre.

3.3. Perspectives d'évolution : vers une approche plus inclusive et égalitaire

3.3.1. Vers un congé parental partagé et une responsabilisation des pères

Pour déconstruire les stéréotypes liés à la maternité et réduire la charge qui pèse exclusivement sur les femmes, une évolution majeure serait l'instauration d'un congé parental partagé. Actuellement, la loi tunisienne prévoit un congé paternité de 10 jours, ce qui est largement insuffisant pour encourager un réel partage des responsabilités familiales (Loi 2024-44, art. 13, p. 16).

Des pays comme la Suède ou la Norvège montrent que l'allocation d'un congé parental important aux pères favorise une égalité plus profonde en matière d'emploi et réduit les stéréotypes liés au genre (OCDE, 2022, p. 64).

3.3.2. Promotion d'une culture organisationnelle inclusive

Au-delà des textes de loi, il est crucial de sensibiliser les employeurs et de promouvoir des pratiques managériales innovantes favorables à la parentalité :

- Télétravail et flexibilité horaire, permettant de concilier les responsabilités familiales et professionnelles ;
- Mise en place de structures d'accueil pour enfants ;
- Programmes de sensibilisation aux enjeux de genre et de parentalité.

Ces actions contribuent à une transformation des mentalités et réduisent la stigmatisation liée à la maternité.

3.3.3. Extension des protections aux travailleuses précaires et informelles

La situation des femmes en emploi informel ou en contrats précaires est particulièrement vulnérable. Ces catégories échappent souvent à la protection juridique, ce qui creuse les inégalités sociales et économiques (INS, 2023, p. 50).

Une réforme ambitieuse devrait donc viser à étendre les droits sociaux et protections à ces femmes, par exemple via :

- Une généralisation de la couverture sociale ;
- La formalisation progressive du secteur informel ;
- Des dispositifs d'accompagnement spécifique.

4. 3.4. Synthèse critique et enjeux futurs

La loi n°2024-44 marque un progrès important, mais elle ne peut à elle seule résoudre toutes les inégalités structurelles. Sa réussite dépendra de :

- L'effectivité de son application, notamment par un contrôle rigoureux et des sanctions adaptées ;
- La transformation des représentations sociales sur la maternité et le rôle des femmes ;

- L'adoption de mesures complémentaires favorisant un partage égalitaire des responsabilités familiales.

L'enjeu est d'atteindre une égalité réelle, où la maternité est valorisée sans devenir un frein professionnel, et où hommes et femmes partagent équitablement les responsabilités familiales.

Conclusion : Réparer l'invisible, sculpter l'équité

La maternité n'est pas un accident de parcours dans une carrière, ni une parenthèse dans une vie professionnelle. Elle est un acte de continuité humaine, un espace de vulnérabilité assumée, de puissance silencieuse, et de création. Pourtant, dans le monde du travail, elle reste trop souvent perçue comme une anomalie, un ralentissement, un désavantage. Le droit, lentement, tente de réparer cette injustice — non par la neutralité, mais par la reconnaissance de la différence comme richesse.

La loi tunisienne n°2024-44 s'inscrit dans ce geste réparateur. En allongeant le congé maternité, en sécurisant l'emploi, en aménageant les conditions de travail, elle cherche à donner à la maternité la place qu'elle mérite : celle d'un temps de vie respecté, inscrit dans le tissu des droits fondamentaux. Mais si cette loi trace les contours d'un progrès indéniable, elle n'épuise pas la promesse d'égalité. Car la maternité ne doit pas devenir une exception à gérer, mais une condition à partager, à protéger, à célébrer.

Là où le juridique rencontre le symbolique, l'art et la justice sociale se rejoignent. Imaginer une société où le congé parental serait un droit partagé, où la naissance ne mettrait pas la carrière entre parenthèses, où la femme ne serait plus vue comme un "risque RH", c'est faire acte de création. C'est sculpter une éthique du soin, une esthétique de l'équité, où la maternité ne serait plus un poids, mais une architecture invisible sur laquelle se bâtit l'avenir collectif.

En définitive, protéger la maternité, ce n'est pas seulement garantir des semaines d'absence rémunérées : c'est donner corps à une société plus juste, où le droit ne se contente pas de dire ce qui est, mais tente — comme une œuvre en devenir — de révéler ce qui devrait être.

Références bibliographiques complètes

- CEDAW, *Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*, Nations Unies, 1979, art. 11.
- INS (Institut National de la Statistique), *Rapport sur l'emploi féminin et l'économie informelle*, Tunis, 2023, pp. 45-50.
- INS, *Rapport sur l'emploi féminin et l'économie informelle*, Tunis, 2023, p. 44.
- Loi n°2024-44 du 12 août 2024 relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité, *Journal Officiel de la République Tunisienne* (JORT), août 2024, pp. 12-18.
- OCDE, *Family Database*, 2022, pp. 56, 59.

- OCDE, *Family Database*, 2022, pp. 56-60.
- ONU, *Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)*, 1979, art. 4.1.
- Organisation Internationale du Travail, *Convention n°183 sur la protection de la maternité*, Genève, 2000, pp. 3-7.
- Rawls, J., *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.
- République Tunisienne, *Code du travail*, JORT, 2006, art. 64 à 66, pp. 38-40.
- République Tunisienne, *Loi n°2024-44 du 12 août 2024 relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et le secteur privé*, JORT, août 2024, pp. 12-18.
- République Tunisienne, *Loi n°2024-44 du 12 août 2024 relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité*, JORT, août 2024, articles 3, 6, 7, 9-10, pp. 13-15.
- République Tunisienne, *Loi organique n°2017-58 du 11 août 2017*, art. 3 et 10, JORT, 2017.
- Sen, A., *Inequality Reexamined*, Harvard University Press, 2000, p. 43.
- Union Européenne, *Directive 92/85/CEE du Conseil*, 19 octobre 1992, JOUE, art. 8-10.
- INS, *Rapport sur l'emploi féminin et l'économie informelle*, Tunis, 2023, pp. 50, 52, 55.
- Loi n°2024-44 du 12 août 2024 relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité, JORT, août 2024, articles 6, 13, pp. 14, 16.
- OCDE, *Family Database*, 2022, pp. 60-64.